정부 2대 지침관련 한국노총 대응지침

- 고용노동부, “공정인사 지침, 취업규칙 해석 및 운영 지침” 관련 -

2016. 2.

현장과 함께! 국민과 함께!
한국노동조합총연맹
FEDERATION OF KOREAN TRADE UNIONS

Ⅰ. 개요 및 대응방향

1. 정부지침 추진 개요

- 정부여당는 9. 15 노사정 합의 이후, 미합의된 5대 노동입법을 강행 추진하는 한편, 공공부문의 성과연봉제 일방도입 및 일반해고 및 취업규칙 일방변경 지침의 조기시행 등을 천명함. 이에 한국노총은 정부여당의 합의파기 행위의 중단을 촉구하고, 한국노총 위원장 국회 앞 1인 시위전개, 노사정 합의파기 및 전면적인 투쟁돌입을 거듭경고함.
- 그럼에도 정부는 "근로계약 및 취업규칙 변경관련 사항은 일방적으로 시행하지 않고 충분한 노사정 협의를 거쳐 마련한다"는 노사정 합의를 위반하여 지난해 12월 30일 정부지침 초안의 공개했으며, 이에 한국노총이 노사정 합의 파기를 선언하자, 지난 1월 22일 정부는 최종안을 발표하고, 1월 25일 지침을 시행하기에 이름.

2. 한국노총의 대응방향

- 정부는 '노동개혁 실천을 위한 공정인사·취업규칙 지침'이란 2개 지침을 최종발표하면서, 지침이 대다수 '성실한 근로자에게 고용안정 장치로 역할을 할 것', '성과에 따른 보상으로 일하는 분위기 조성 등의 주장을 하고 있으나 실제는 성과주의 인사 및 임금체계 도입으로 사용자 주도의 쉬운 해고 및 노조 교섭기능의 무력화를 의도하고 있음.
- '공정인사 지침'(이하 '쉬운해고 지침')은 '통상해고' 개념을 자의적으로 해석하여 '업무능력 결여, 근무성적 부진'만으로도 해고의 정당한 사유가 인정되고, 일정한 절차만 거치면 해고가 가능하다는 데 초점을 맞추어 쉬운 해고방안을 안내하고 있음.
- '취업규칙 지침'은 임금피크제 도입 또는 임금체계 변경으로 임금·근로조건이 저하되는 경우에는 근로기준법(제92조 제1항 단서)에 따라 노조 또는 근로자 과반수의 집단적 동의절차를 거쳐야 함에도, 예외적으로 동의절차 없이 시행이 가능한 판례법리를 초점을 맞추어 소개하고 있어 사측의 '취업규칙 일방변경'지침에 해당됨.
- 한국노총 산하조직은 현행 근로기준법 제23조(해고 제한), 제94조(취업규칙 변경절차) 및 판례에 비추어도 정당화 될 수 없는 정부지침의 위법성과 문제점을 인식하는 한편, 부당한 지침에 근거한 사측의 교섭요구를 전면 거부하고 무력화 투쟁을 전개해야 함.
- 본 대응지침은 사측의 정부지침에 근거한 저성과자 해고 제도의 도입 및 임금피크제, 성과연봉제 등 임금체계의 변경요구에 맞서 한국노총 중앙과 산별연맹, 현장 단위조직의 교섭대응 방침 및 투쟁지원 체계를 확립하고자 함.

Ⅱ. 정부지침의 의도 및 문제점

1. 정부지침의 의도와 위헌성

- 정부는 '저성과자 해고지침'을 『공정인사 지침: 직무능력과 성과 중심의 인력 운영을 위한 가이드북』 형태로 발간함. 이번 지침은 제목에서 알 수 있듯이, 근로계약의 체결부터 고용기간중 인사평가, 근로계약의 해지(해고)까지 인사의 전 과정을 사용자의 인사재량권 하에서 성과주의로 개편하겠다는 의도임.
- 문제는 정부가 근로기준법에 명시된 해고제한와 취업규칙 변경 요건을 임의적으로 확대해석한 행정지침 규정하는 것은 위법적 소지가 다분하며, 중요한 근로조건 내용과 기준을 법률로 정하도록 한 헌법의 취지(제32조)를 심각히 훼손하는 고용노동부의 위법한 행정권 남용 행위에 해당됨.

2. 정부지침의 위법성과 문제점

1) 위법성

- 개별노동자의 고용보호 등에 관한 노동기본권 및 핵심적 노동기준을 규율하는 것은 반드시 법률을 통해 마련되어야 하고[1], 입법과정을 통해 사회적 공론화 과정을 거치고 그 내용이 타당성 여부를 철저히 검증해야 할 사항임.
- 노동부와 같은 행정기관은 노동기본권을 제한하는 사항에 대해 입법이 이루어진 뒤에서야 비로소 "지침 등"을 마련하는 절차를 거칠 수 있고, 그 범위도 법률이 위임한 범위에서 제한적으로 규정되어야 함.
- 2개 지침은 해고와 취업규칙의 요건을 완화하여 개별노동자들의 노동기본권을 침해하는 내용을 담고 있으면서도 법률이 아닌 지침의 형식으로 마련되었다는 점, 지침을 제정할 만한 법률상 위임규정이 없다는 점, 현행 법령·판례를 왜곡하고 있다는 점 등을 고려할 때 2개 지침은 위법·부당한 것임.

2) 행정지침의 문제와 한계

1) 헌법 제32조3항)은 "근로조건의 기준은 인간의 존엄성을 보장하도록 법률로 정한다"고 규정하고 있음.

- 이와 같은 정부지침의 위헌성 및 위법성에도 불구하고, 고용노동부는 그동안 주요 노사관계 이슈(근로시간면제제도 및 복수노조 제도시행, 통상임금 문제 등)가 발생했을 때마다, 이와 관련된 고시, 예규, 훈령, 가이드라인, 매뉴얼(이하, "지침 등") 등 다양한 형식과 명칭으로 행정지침을 만들어 제시하였음.
- 이러한 "지침 등"은 일선 근로감독관의 업무처리를 위한 내부규정에 불과하여 법적 구속력이 없음에도 노동관계법령의 해석·적용의 실질적인 기준으로 취급 되어 노·사 당사자에게 막대한 영향을 미치고 있다는 것이 현실임.
- 반면 정부지침 자체로는 법적 효력이 없으므로 정부지침에 대한 위헌소송, 효력정치 가처분 등의 직접적인 법률소송은 불가능하고, 지침에 의한 일선 근로감독관의 노사관계 개입 또는 사측의 일방적 노동조건 변경 등의 문제가 발생한 이후에야 법률대응이 가능하다는 문제점도 있음.
- 이에 우선 정부지침의 위법성과 문제점을 인식하는 한편, 부당한 지침에 근거한 사측의 교섭요구 전면 거부 등의 조직적 대응, 부당한 근로감독 개입행위에 대한 법률대응으로 현장에서 정부지침을 철저히 무력화 시켜는 것이 필요함.

Ⅲ. "공정인사 지침: 직무능력과 성과 중심의 인력운영을 위한 가이드 북"(일명 '쉬운해고 지침')의 문제점

1. '쉬운 해고 지침'의 요지

○ 업무능력 부족, 성과부진는 저성과자는 일반 해고대상자 : 해고 사유에 따라 해고 유형을 통상해고, 징계해고, 경영상해고로 구분한 뒤, 통상해고를 "사용자가 '근로자의 근로계약 상의 근로제공 의무를 이행하지 못함'을 이유로 근로자를 해고하는 것"으로 정의하고 '업무능력 결여 근무성적 부진 등을 이유로 한 해고'도 통상해고에 해당하는 것으로 포섭하고 있음.

○ 해고의 '객관적이고 공정한 평가 기준'으로서 △합리적인 평가기준 설계 △평가방법의 타당성 △평가실행의 신뢰성 △공정하고 객관적인 평가에 따른 대상자 선정 등의 요건 제시

○ 해고의 사전적 절차로서 △업무능력 향상을 위한 교육훈련의 기회 제공 △배치전환 등 고용유지 노력을 제시한 뒤 최종적으로 △업무능력 또는 성과개선의 여지가 있는지 여부 △업무에 상당한 지장을 초래하는지 여부를 판단하여 해고 대상자를 정하도록 하고 있음.

2. '일반해고 지침'의 문제점

1) "업무성과 부진"만으로 정당해고 사유될 수 없음(근로기준법 제23조 취지 위배)

- 근로기준법 제23조 제1항은 정당한 이유 없는 해고를 금지하고 있고, 해고의 정당한 사유에 대하여 우리 법원은 "사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있는 경우에 행하여져야 그 정당성이 인정되는 것" 이라고 일관되게 판결하면서, 노동자의 귀책사유가 없는 사유에 기초한 해고를 인정하지 않고 있음
- 해고의 정당성 판단요소로 사유·절차·양정을 모두 판단해야 함. 이는, 민법상 고용계약의 해지에 대한 노동법상 제한으로 사용자의 의한 일방적인 근로계약 해지로부터 노동자를 보호하기 위한 취지임.

> * 근로기준법 제23조(해고 등의 제한) ① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌을 하지 못한다.

- 정부 지침은 우리 근로기준법상 해고제한의 취지와 원칙을 근본적으로 호도하여 업무능력 부족 및 근무성적 부진 자체도 근로자의 일신상 사유(근로자의 부상 질병 등' 신체적, 정신적인 장애 내지 결함 등)로 근로제공이 불가능한 경우와 동일하게 통상해고 사유에 해당한다고 규정하고 있음.
- 지침은 판례를 근거로 "업무능력 또는 성과개선의 여지가 없거나 업무의 상당한 지장을 초래하는 경우 업무능력 결여, 근무성적 부진 등을 이유로 통상해고를 할 수 있다"라는 근거로 판례를 제시하고 있지만 실제 구체적 사실관계 및 판례 법리를 왜곡한 것임.
- 대법원은 단순히 업무능력 결여, 근무성적 부진으로 바로 해고하는 것이 아니라, △업무명령 위반, △근태불량, △기업의 중대한 지장을 미치는 등 징계에 준하는 사유가 있을 때 비로소 해고를 하였고, 이 경우에도 그 사유와 절차, 양정의 정당성을 판단해 옴.
- 지침은 단순한 업무능력 결여, 근무성적 부진을 법적 근거 없이 통상해고 사유에 해당한다고 단정하였으므로 부당함.

2) 법과 판례의 취지와 다른 지침의 제시는 현장의 혼란과 분쟁만 초래

- 노동부는 근로기준법이 획일적, 추상적이라서 불확실하다는 이유를 들면서 통상해고의 기준과 절차를 지침으로 정해야 한다는 주장을 함.
- 근로기준법이 정하고 있는 '정당한 이유에 관한 해고'는 근로자보호를 목적으로 광범위하고 폭넓게 정의하여 엄격하게 해석하고 있음.
- 우리 근로기준법 및 정착된 판례는 "해고의 정당한 사유"에 관한 충분하고 객관적인 원칙과 기준을 명확히 제시하고 있음(2003헌바12, 2012헌바375).

> ► 헌법재판소도 근로기준법이 정한 해고의 '정당한 이유'(제23조 제1항)가 명확성의 원칙에 위배되는지가 문제된 사안에 대해서, "오랜 기간 판례가 집적되어 '해고'에 있어서 '정당한 이유'란 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유를 의미하게 되었고", "모든 해고의 형태를 일일이 구체적, 서술적으로 열거하여 그 정당성의 범위를 규정하여 두는 것은 입법 기술상 불가능하거나 현저히 곤란하다"고 결정(2013. 12. 26. 2012헌바 375 결정)한 바 있음.

- 판례를 통해서도 확인할 수 있듯이 해고의 정당성은 구체적인 사례에 따라 판단하여야 하는데, 해고의 절차와 기준을 명확화 한다며 극히 예외적 판례를 일반화 시키는 것은 오히려 불확실성을 가중시키고 산업현장의 혼란과 노사분쟁만 초래할 것임.

3) 정부지침이 인용한 판례의 문제

- 노동부는 "업무능력 또는 성과개선의 여지가 없거나 업무의 상당한 지장을 초래하는 경우 업무능력 결여, 근무성적 부진 등을 이유로 통상해고를 할 수 있다"라는 근거로 판례를 제시하고 있지만 실제 구체적 사실관계 및 판례 법리를 본질과 다르게 인용하고 있음.
  - ► 노동부가 인용한 대다수 판결은 통상해고가 아닌 징계해고 사유에 해당하거나 업무능력 결여 및 근무성적 부진을 징계의 사유로 삼을 수 있는 경우라도, 실적부진만을 이유로 해고(근로관계 단절)할 정당성을 인정하지 않은 사례임[2]
  - ► 업무능력 결여, 근무성적 부진 등을 징계의 사유로 징계해고를 인정한 경우라도, 다수의 비위행위가 존재하여 징계해고 사유로 함께 고려된 판례들임[3]
  - ► 노동부가 인용한 대부분의 판결은 해고처분이 아닌 단순한 근로계약상의 인사권 행

2) 서울행법 2005구합23879(대법원 2006두18287), 서울행법 2003구합23769
3) 서울행법 2010구합41673(대법 2014다31677), 서울행법 2003구합39306(대법 2005두9729), 서울행법 2010구합42263(대법 2012두4760)

사(근속 승진 누락, 성과급 지급, 대기발령)에 국한된 것[4)]

- 업무성과부진만으로 해고의 정당성을 인정한 판례는 거의 찾아 볼 수 없으며 대부분 판례는 근로자의 비위행위, 무단결근 등 여타 징계사유와 더불어 현저한 성과부진으로 사회통념상 고용관계의 유지가 불가능한 경우에 한하여 해고사유로 인정됨.

4) 사법·입법부의 권한을 침해하는 행정권 남용

- 지침은 관련 판례에 따라 기준과 절차를 명확하게 하는 것이라고 거듭 강조하고 있음. 수십년간 쌓아온 부당해고 판결들에도 불구하고 관련 지침을 만드는데 소극적이던 고용노동부가 굳이 일반해고를 대상으로 지침을 만들겠다는 의도가 불분명함.
- 근로기준법 제23조는 위임조항의 형태를 취하고 있지 않기 때문에 지침을 만들 만한 법적근거가 없고, 이를 판단하는 것은 법원의 몫이므로 고용노동부가 일반해고 지침을 시행하는 것은 사법·입법부의 권한을 침해하는 행정권 남용행위에 해당함.

5) 객관적이고 공정한 평가는 불가능한 문제

○ 인사평가제도 설계·도입에 있어 공정성 담보의 어려움

- 인사평가제도를 설계·도입하는데 사용자에게 광범위한 재량권이 인정되어 있고, 고용노동부는 '90년대 후반부터 이른바 신인사관리제도·성과연봉제의 전제로 인사평가제도 도입을 적극 홍보하여 왔으나 실제 기업들에서 활성화되진 못했음.
- 객관적 평가가 가능한 업무는 실적 등 계량지표가 집계되어야 하는데 이와 같은 업무는 제한적이고, 실제 기업에서 사용되는 지표는 대부분 주관적(정성적)인 내용들로 구성되어 있어 평가결과를 수용하기 힘들어 평가자·피평가자 모두 평가제도를 도입·시행하기를 꺼려하기 때문임.

○ 인사평가의 시행 공정성 입증곤란

- 공정한 평가제도를 하였는지 여부를 확인할 수 없다는 데 가장 큰 문제가 있음.
- 상급자가 주관적 기준에 따라 평가점수를 부여하는 방식으로 인사평가가 실시되는 것이 보통인데, 평가결과에 피평가자가 이의를 제기하더라도 평가결과가 공정한지 여부를 확

4) 대법원 2005두13247, 수원지법 2012나6377(대법원 2013다22195), 울산지법 2012가단562, 서울행법 2008구합46477

인하기 힘든 경우가 많고, 그 결과를 확인했다하더라도 적정성을 증명하기 곤란함.

- 지침에 따라 저성과자 퇴출을 위한 인사평가를 실시하는 경우 사용자가 의도적으로 낮은 인사고과를 부여할지라도 근로자측이 이에 대응하는 것은 사실상 불가능함.

6) 일반해고의 보완수단인 '교정 등 개선기회 부여와 재평가'도 사용자가 실시하는 것에 불과

- 고용노동부는 지침에 저성과자란 이유로 무조건 해고되는 것이 아니라 교육을 제공하거나, 배치전환 등의 기회를 일정기간 부여하고 평가를 다시하는 내용을 포함하겠다고 밝힌 바 있음. 즉, 고용노동부는 교정 등 개선기회를 부여한다는 것을 확실히하여 무분별한 해고를 하지 못하도록 지도하겠다는 것임.
- 인사평가 및 일반해고와 마찬가지고 '교정 등 개선기회 부여'도 사용자가 실시하는 행위에 불과하며, 교정 등의 개선기회가 얼마나 합당한 수단일지 담보할 수 없고, 재평가 과정에서 다시 저성과자로 평가하는 것을 막을 수단은 존재하지 않음.
- 오히려 교정 기회 부여라는 명목으로 사용자가 해고를 막기 위해 최선의 노력을 다했다는 사용자의 명분쌓기용으로 활용될 여지가 높고, 이 과정에서 자발적 퇴사를 유도하기 위해 생소한 업무를 부여하거나 무의미한 교육을 부여하는 등으로 근로자를 괴롭히는 '학대 해고'를 합법화하는 수단으로 악용될 가능성도 있음.

【첨부1】: 직무능력과 성과중심 인력운영 가이드북(공정인사 지침)의 주요내용 및 문제

Ⅳ. 「취업규칙 해석 및 운영 지침」(일명 '취업규칙 불이익변경 지침')의 문제점

1. '취업규칙 불이익 변경 지침'의 요지

- 취업규칙관련 정부지침은 임금체계 변경 및 임금피크제 도입 등이 불이익변경에 해당하더라도 변경의 필요성과 내용이 법적 규범성을 인정할 수 있을 정도로 사회통념상 합리성이 있는 경우 근로자 과반수의 집단적 동의를 받지 않더라도 유효하다는 해석에 초점을 맞추고 있음.

- 사회통념상 합리성 유무는 ① 취업규칙의 변경으로 근로자가 입게 되는 불이익의 정도, ② 사용자 측의 취업규칙 변경 필요성의 내용과 정도, ③ 변경 후 취업규칙 내용의 상당성, ④ 대상조치 등을 포함한 다른 근로조건의 개선 상황, ⑤ 노동조합 등과 교섭 경위와 노동조합이나 다른 근로자의 대응, ⑥동종 사항에 관한 국내 일반적인 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단할 것.
- 구체적으로 판단에 있어 다음과 같은 임의적 해석기준을 제시함
  i) 합리적 수준의 임금피크제 도입방안을 마련하고 근로자 동의를 얻고자 성실히 노력했음에도 불구하고 근로자 측의 거부 등으로 동의를 얻지 못한 채 취업규칙이 변경된 경우 사회통념상 합리성 법리를 적용하여 인정 가능
  ii) 근로자의 과반수로부터 임금체계 개편 등에 관한 협의 권한을 위임받은 근로자대표와 성실히 협의한 경우 사회통념상 합리성 인정 시 중요한 고려 요소가 될 수 있음.
  iii) 임금체계 개편시 사업주가 임금 지급방식이나 임금체계 자체를 바꾸는 것은 노무관리나 생산성 향상 등 경영상 필요에 기초한 것으로서 원칙적으로 취업규칙의 불이익변경으로 볼 수 없음.

2. '취업규칙 불이익 변경 지침'의 문제점

1) 취업규칙의 불이익 변경과 근로자 집단의 동의 절차의 취지

- 취업규칙 불이익 변경이란 명칭 여하에 관계 없이 개별노동자가 종전에 가지고 있던 기득의 권리나 이익을 박탈하여 근로조건을 낮추거나 복무규율을 강화하는 것을 말하며, 근로기준법 제94조 제1항 단서는 사용자가 취업규칙을 불이익하게 변경하고자 하는 경우 근로자집단의 동의를 받을 것을 요구하고 있음.
- 이는, 노동자가 근로관계에서 사회적 약자라는 특성을 감안하여 사용자가 취업규칙을 일방적으로 권한을 남용하여 개정하지 못하게 하고, 나아가 취업규칙 관련 규정 중 사용자-근로자 간 실질적 대등결정을 유도하기 위한 유일한 제도라고 볼 수 있음.

2) 임금체계 변경 및 임금피크제 도입은 명백히 취업규칙 불이익 변경에 해당

○ 임금체계 변경은 불이익 변경에 해당

- 고용노동부의 최근 임금체계 관련 자료에서 예정하고 있는 임금체계의 변경은 우리나라의 기업들이 가장 많이 도입하고 있는 연공급을 직능·직무·성과급으로 변경을 의미하는 것으로 보임.

- 기존의 연공급에서 직능·직무·성과급으로 임금체계를 변경할 경우 대다수 사업장에서는 일부 직원들의 임금이 증가하는 만큼 나머지 직원들의 임금이 감소할 것으로 예상되기 때문에 명백하게 불이익 변경에 해당되는 것으로 판단됨[5]
- 임금체계의 변경에 따른 취업규칙 불이익 변경 문제는 고용노동부 주장하는 바와 같이 경영권 해당여부를 판단할 사항이 아니고, 그로 인하여 대상자들의 일부라도 기존 근로조건에 불이익한 변경이 발생되는지 여부를 판단해야 문제임. 마치 임금체계의 변경은 경영권 사항이기 때문에 사측의 임의적 변경이 가능한 것처럼 논리를 전개하는 것은 과거에 고용노동부의 유권해석[6]에도 배치되는 것임.

○ **임금삭감을 초래하는 임금피크제 도입은 불이익 변경에 해당**

- 고용노동부는 "정년을 연장하면서 현재의 정년 이후부터 임금을 감액하는 경우[7]에는 현재의 정년 이후에 정해진 임금 등이 없어 비교대상인 근로조건이 없으므로 일률적으로 불이익변경이라고 판단하기 어렵다는 견해도 있(다)"고 하나,
- 위와 같은 '정년연장형 임금피크제'는 불이익 변경으로 보는 것이 타당함. 왜냐하면, ① 60세 정년은 고령자법에 따른 당연히 효력이 발생하는 것이며 이는 강행규정인 점, ② 임금피크제 도입과 정년연장을 상호 대가관계 또는 연계성을 부여한 것으로 의제해야한다고 하고 있으나 고용노동부의 독단적인 판단일 뿐, 아무런 근거가 없는 부분인 점, ③ 동 제도가 도입되면, 도입되지 않았을 경우와 비교하여 기준 시점부터 연장된 정년까지의 임금이 대폭 감소됨을 고려한다면 취업규칙 불이익 변경에 해당됨.

3) '사회통념상 합리성 이론'을 적용하여 근로자집단의 동의 없이 취업규칙 변경을 강제한다는 것은 근로기준법의 강행규정 위반

- 고용노동부가 사용자 일방적인 임금피크제 도입이 가능하다고 근거를 들고 있는 '사회통념상 합리성' 이론은 본래 일본에서 확립된 이론에 해당하는 반면, 우리나라는 이와

---

5) 대판 1993. 5. 14, 93다1893

6) 2002.04.24, 근기 68207-1760, "……귀 사업의 급여제도를 변경함에 있어 기존의 연공서열식 임금체제에서 능력 및 업적을 평가하는 능력중시형 임금체제(연봉제)로 전환하는 경우 일부 근로자는 종전보다 유리해지고, 일부 근로자는 불리해지는 경우라면 전체적으로 불이익변경에 해당된다고 볼 수 있을 것인 바, 이 경우 동법 제97조에 의한 취업규칙 불이익변경의 절차를 거쳐 적법하게 변경해야 유효할 것으로 사료됨."

7) 고용노동부는 ①'정년연장형 임금피크제'만이 불이익 변경이 대상이 아닐 수도 있음을 염두 해두고 있는 것으로 보임. ②'정년보장형 임금피크제' 정년 보장을 전제로 기존의 임금을 삭감하는 것이기 때문에 다른 조치가 동반되지 않는 한 불이익 변경에 해당함이 명백하며, ③'고용연장형 임금피크제'는 애초에 불이익 여부가 다투어질 수 없음.

달리 근로기준법 제92조에 취업규칙 불이익 변경 시 근로자집단의 동의를 받을 것을 규정하고 있으므로, 이를 우리나라에 그대로 적용시켜 법적 절차를 거치지 않은 무효한 취업규칙을 유효하게 해석하는 것은 부적절함.

- 판례가 '사회통념상 합리성' 이론을 취업규칙 불이익 관련 사건에서 기계적으로 언급하고 있지만, 대법원에서 이를 원용하여 무효인 취업규칙을 유효하게 해석한 것은 '89년 법제정 이래로 딱 2건[8]일 정도로 극히 예외적으로 적용되는 것이며,
- '사회통념상 합리성' 이론을 원용한 두 사건 모두(99다70846과 2001다16722) 그 배경에는 노동조합의 '합의' 내지 그에 준하는 사정이 있었던 것으로 동의 절차를 배제하는 것과는 성격을 달리하고 있음.
- 사법부에서도 극히 예외적으로 적용하는 법리를 확대해석하여 근로기준법이 규정하고 있는 근로자집단의 동의 절차를 배제하는 것은 명백히 근로기준법 위반임.

【첨부2】: 「취업규칙 해석 및 운영 지침」 개정안 주요내용 및 문제점

Ⅴ. 한국노총 대응방향 및 현장 단위 대응지침

1. 한국노총 중앙 및 산별 대응방침

1) 정부지침 무력화 및 현장 교섭 · 투쟁지원 체계 확립

○ "정부지침의 위법성과 문제점" 관련 긴급 정책토론회 개최(2월 3일)

- 지침초안 발표된 이후, 많은 학자 및 전문가들이 지적한 바 정부지침의 위법성 및 문제점에 대한 여론 부각 및 현장 인식 확산을 위한 긴급 정책토론회 개최

○ 한국노총 중앙과 산별연맹, 현장 교섭을 연계하는 지침무력화 대응활동

- 정부지침 대응교섭 지침 배포 : 사측의 저성과자 퇴출프로그램 및 취업규칙 불이익변경 기도에 대한 대응교섭 지침 제작배포

8) 강선희, "임금피크제 도입을 위한 취업규칙 불이익 변경 시 동의방법과 사회통념상 합리성", 「노동리뷰 2015년 11월호」, 70쪽

- 현장투쟁 신속대응팀 운영 : 신속한 현장 교섭지원 및 투쟁지원 체계 구축을 통한 정부 지침 무력화 활동 전개

► 신속대응팀 중앙합동 대응체계 : 교섭 및 투쟁지원(조직강화처 노사대책국) + 법률대응(중앙법률원) + 대정부 정책대응(정책본부)

► 현장 핫라인 연결체계 : "쉬운해고 및 취업규칙 일방변경 긴급 신고센터"(한국노총 산하 시·도지역본부 및 노동교육상담소 → 한국노총 중앙투쟁상황실 및 산별연맹 투쟁상황실 신속 연락체계 구축

○ 전조직적 "쉬운해고 및 취업규칙 일방변경" 불법지침 분쇄투쟁 전개

- 한국노총 중앙투쟁상황실 및 산별 회원조합 투쟁상황실 설치
- 전국 단위노조대표자 및 상근간부 결의대회(1/29, 서울역 광장)
- 한국노총 중앙집행위원회(2/15) → 한국노총 전국대의원대회(2/24, 총력투쟁 계획 확정 예정) → 전국 시·도지역 순회교육 실시(한국노총 투쟁방침 설명회 개최 예정)

2) 소송지원 및 법률대응

○ "쉬운해고 및 취업규칙 일방변경 긴급 신고센터" 운영

- 한국노총 중앙과 산별연맹, 각 시·도 지역본부, 지역 노동법률상담소에 "쉬운해고 및 취업규칙 일방변경" 신고센터 설치, 사용자의 일방적 임금·근로조건 불이익변경 등 불법행위와 행정관청의 위법행위 신고접수, 감시활동 전개

* 연락처 : 한국노총 중앙법률원 02- 6277- 0025~0027)

○ 법률자문 및 소송지원 서비스 강화

- 사측의 저성과자 퇴출프로그램 및 취업규칙 불이익변경 기도에 대한 법률자문 및 소송지원 서비스 제공
- 한국노총 산하 조직 및 미가입 사업장에 대한 차별없는 소송 지원활동 전개

○ 고용노동부의 지침 남용 및 위법행위 방조행위에 대한 법적 대응

- 사측의 일방적인 저성과자 퇴출제 도입 및 해고 사건 발생, 일방적 임금·노동조건 불이익변경 등 발생시 지침을 이유로 한 현장 근로감독관의 감독소홀, 형사고발 지체 등 직무태만 행위에 대한 철저한 감시

- 지침에 근거하여 사측의 임금체계 불이익변경 등 위법행위 방조 및 노사관계 부당 개입 시 직권남용 협의로 해당 근로감독관 및 고용노동부 장관 고발 추진

○ 국가인권위원회 진정 절차 추진 등 법률대응 활동 전개
- 국가 기관에 의한 쉬운 해고, 노동인권 침해행위에 대한 인권위 진정 및 지침 시정권고 촉구, 국제노동기구(ILO) 제소 추진 활동전개
- 정치적으로 고용노동부 장관 탄핵소추 및 해임건의 추진

2. 현장 교섭 대응지침

1) 업무능력 부족, 성과부진을 해고사유에 포함시키거나 직무 · 성과주의 임금체계 개편을 추진하려는 사측의 요구에 단호히 대응할 것

- 저성과자에 대한 평가기준 및 퇴출절차, 임금피크제 도입이나 임금체계 변경은 명백한 임금 · 노동조건의 불이익 변경이며, 특히 조합원의 고용 및 임금, 노동조건을 보호 · 개선해야 하는 노조의 존립 근거를 위협하는 것인바 모든 수단을 동원하여 단호히 대응해야 함.
- 특히 정부가 추진하려고 하는 성과주의 인사체계 및 임금체계의 도입은 심각한 고용불안 및 장기적으로 절대적 임금수준의 저하를 초래하게 되는 바 사용자의 일방적인 추진을 결코 용인해서는 아니 됨.
- 인사제도 및 임금체계 개편 시 노동조합과 반드시 사전 합의하도록 하고, 이러한 절차를 위반할 경우에는 그 내용의 불이익여부를 불문하고 노조는 무효화 투쟁을 강력히 전개해야 함.
- 특히 최근 시행된 정부지침을 근거로 한 사측의 일방적인 성과주의 인사체계 및 임금체계의 도입 움직임에 대해서는 이를 상급단체(한국노총 중앙, 소속 산별 및 시도지역본부)에 알리고 공동투쟁 및 교섭지원, 법률자문을 받도록 함.

2) 단체협약상 “취업규칙 제 · 개정시 노동조합 동의” 규정 명확화

- 취업규칙이란 사업장 내 근로조건 등의 통일적 적용을 위하여, 사용자가 마련한 근로자의 복무규율 및 근로조건에 관한 일체의 규율, 규칙 모두를 말하는 바, 사측이 성과주의 인사체계 또는 임금체계의 변경은 취업규칙 제 · 개정형식을 취할 수밖에 없음.

- 노조가 있는 사업장은 단체협약에서 규정한 임금, 근로조건 등은 취업규칙보다 우선하는 효력을 가지므로, 단체협약에 규정된 임금, 근로조건 및 인사, 징계관련 사항을 개정할 경우 반드시 노동조합의 동의를 받아야 함.
- 반면 단체협약에 포함되지 않은 '노동조건 및 근무평가, 복무규율, 인사·징계 등'와 관련한 불이익 변경절차에 대한 노조의 동의 규정을 두고 있지 않거나, '노동조건 및 근무평가, 복무규율, 인사·징계 등'을 취업규칙에 위임하고 있는 경우 노동조건 불이익 변경에 대항할 근거규정 마련이 필요함.
- 취업규칙 제·개정시 반드시 노동조합의 동의를 받도록 하며, 특히 인사평가의 실시 여부와 기준 및 평가절차의 결정, 임금체계나 임금구조, 조직개편의 시행절차, 인력 배치전환·교육훈련·해고 등 고용조정의 기준 및 절차 등은 반드시 단체협약을 통하여 정해야 할 사항으로 명시하고, 단협에 반하여 시행하는 기준 및 처분의 무효로 해야 할 것임.

3) 단체협약에 의한 인사(배치전환, 전보 등) 및 인사평가, 징계(복무규율, 징계사유 등), 교육훈련, 임금체계 제·개정시 노조 참여 및 노사합의 구조 확립

○ 인사위원회, 징계위원회 등의 노사동수 구성 요구

- 인사 공정성의 핵심은 인사평가의 과정 및 결과에 대한 투명성 확보, 평가의 전 과정에의 노동조합 및 근로자대표의 직접적인 참여를 보장하는 것임.
- 무엇보다 노동자의 자주적 조직인 노동조합이 인사 평가기준 마련, 인사평가 과정 참여, 평가오류에 대한 검정 및 시정과정에 참여하는 것이야 말로 인사제도의 공정성, 객관성 확보하는 기초임.
- 정부는 지침에서 공정하고 합리적 인사평기 기준마련을 위하여 노조 및 근로자대표의 의견반영될 수 있도록 해야 한다고 하면서도, 정부는 단체협약 시정지도 계획에서는 노조가 단체협약을 통해 인사경영에 참여하는 것은 사용자의 경영권에 개입하는 '불공정 단체협약' 이라는 이율배반적 태도를 보이고 있음.
- 사업장의 인사기준과 절차가 투명성과 공정성을 위해 인사위원회, 징계위원회 등에 노사대표 공동 구성을 확보하고 특히 노동자들의 고용 및 노동조건에 영향을 미치는 중요한 인사권 행사에 대한 노사합의 구조를 확립해야 함.

○ ‘단체협약상 징계해고의 사유와 절차 등’ 관련 규정의 강화

- 정부지침에 따라 사용자들은 ‘통상해고’를 운운하며 징계사유에 해당되지 않음에도 사실상 징계해고 사유를 구체화 방식으로 성과부진에 따른 징계해고가 가능하게 하려고 시도할 것임.
- 단체협약을 통해 사업장에서 벌어지는 일체의 불이익처분은 징계임을 분명히 규정하고 이는 노사 동수로 구성된 단체협약상 징계위원회를 통해서만 할 수 있도록 절차를 엄격화해야 함
- 또한 징계사유와 종류를 단체협약으로 정하고, 그 이외의 징계성 조치를 할 수 없도록 하며, 단체협약과 상이하게 징계사유나 종류를 열거한 경우, 취업규칙에 추가된 징계사유는 무효임을 명시하고, 취업규칙을 변경할 의무를 규정해야 함.

○ 단체협약상 배치전환·전보 등에 있어 노동조합과 사전합의 절차 마련

- 앞서 언급한 바와 같이 정부지침은 저성과자 해고에 앞서 배치전환, 교육훈련 등을 해고를 회피할 수 있는 합리적인 기회인양 합법적인 절차로 포장하고 있음
- 오히려 잦은 전환배치, 업무와 무관하거나 사직을 유도하는 교육참여를 강제하는 것은 노동자에 대한 괴롭힘을 통한 학대해고를 허용하는 것이며, 잦은 업무 전환으로 성과개선을 더 어렵게 만들어 해고의 구실을 만들기 위한 형식적인 절차에 불과함
- 이에 배치전환이나 전보, 휴직, 대기발령 등이 저성과자 해고 수단으로 악용되는 것을 사전에 차단하기 위한 절차로 노동조합과 사전합의하도록 절차를 강화해야 함.

4) 개별 노동자를 상대로 한 취업규칙 변경 동의 금지 조치 및 사측의 일방적인 저성과자 해고제 도입 및 임금체계 불이익변경 등 위법 행위 발생시 즉각적인 가처분 신청 등 신속한 권리보호 조치 후, 민사소송 진행

○ 개별 노동자를 상대로 한 취업규칙 변경 동의 강요행위 금지

- 정부의 취업규칙 지침을 근거로 사용자는 저성과자 해고제도나 성과급 임금체계 개편 등 ‘쉬운 해고’와 ‘낮은 임금’을 밀어붙이려 할 위험이 커짐
- 사용자는 노동조합을 배제하고 일방적인 취업규칙 변경을 시도하기 위해 단체협약 해지 및 개별 노동자들을 상대로 한 취업규칙 변경 동의 강요, 근로계약서 서명 강요 등을 행할 가능성이 있음

* **개별 동의를 통한 취업규칙 불이익 변경추진은 명백한 위법행위 ;** 근로기준법 제94조는 취업규칙의 불이익변경시 과반수 노조가 있으면 해당 노조의 동의, 과반수 노조가 없으면 근로자 과반수의 회의방식에 의한 집단적 동의, 즉 ① 사용자 측의 개입이나 간섭이 배제된 상태에서 ② 변경내용에 대한 충분한 설명과 근로자 상호간 충분한 의견을 교환하는 과정에 동의절차가 보장되어야 함. 회사 방침에 따른 개별 근로자에 대한 취업규칙 불이익 변경동의는 위법이며, 이에 따른 취업규칙 불이익 변경은 무효임.

- 앞서 언급한 바, 단체협약상 취업규칙 및 조합원의 개별 근로계약서의 내용의 작성·변경시 노동조합과의 사전 합의를 명문화하고, 이를 위반하여 개별 노동자를 상대로 한 취업규칙 변경 동의는 무효이며, 이를 행하는 행위자(사용자 불문)에 대한 징계규정을 명시해야 할 것임.

○ 사측의 일방적인 저성과자 해고제 도입 및 임금체계 불이익변경 등 위법 행위 발생시 즉각적인 가처분 신청 등 신속한 권리보호 조치 후, 민사소송 진행

- 사측의 일방적인 저성과자 해고제 도입 및 임금체계 불이익변경 등 위법 행위 발생시 이를 상급단체(한국노총 중앙, 소속 산별 및 시도지역본부)에 즉시 알림.
- 한국노총 중앙법률원에 법률자문 및 법률지원 서비스를 의뢰하여 즉각적인 가처분 신청 등 신속한 권리보호 조치 후, 민사소송 진행해야 할 것임.

5) 인사평가 기준 및 임금제도 관련 개편논의 참여시 전제조건

- 불가피하게 사측의 인사기준 또는 인사평가 기준 논의, 임금피크제 및 성과주의 임금체계 개편논의를 진행해야 할 경우 다음과 같은 선결요구를 제시할 것

► 인사위원회, 징계위원회 등의 노사동수 구성, 고용안정협약 체결, 취업규칙 변경시 단체협약상 노동조합 동의 신설

► 인사평가 기준 및 성과평가 기준을 위한 노사 동수의 제도개편위원회 설치, 동 제도개편위원회에서 노사합의안 도출시 제도시행 검토

< 첨부1 >

직무능력과 성과중심 인력운영 가이드북('공정인사 지침')의 주요내용 및 문제

구분	정부 지침의 주요 내용	문제점
Part Ⅰ. 필요성 등	○ 우리 근로기준법의 획일적·추상적 기준("정당한 이유"란 해고사유)이 인력운영의 불확실성 가중(4~10쪽) - 노동시장의 선순환 악화, 분쟁증가, 정규직 보다 비정규직·하도급 활용 증가 초래… 판례 등에 기초한 기준절차 제시하여 인력운영의 예측가능성, 공정성 확보하고자 함. - 보도자료, 노사에게 실질적 도움이 되는 균형된 내용 마련	► 우리 근로기준법 및 정착된 판례는 "해고의 정당한 사유"에 관한 충분하고 객관적인 원칙과 기준을 명확히 제시하고 있음(2003헌바12, 2012헌바375). - "직무성과 중심의 인력운영"이란 지침 제목으로 노동부는 성과주의 임금제도·인사운영을 위해 일반해고를 활용하라는 의도를 분명히 함. - 내용적으로도 판례가 업무성과부진 자체만으로 해고를 인정하고 있는 것처럼 판례를 부분적으로 인용하는 등 사용자 입장에서 저성과자에 대한 통상해고 활용방안을 안내하는 식으로 구성되어 있음. <참고> 업무성과부진만으로 해고를 인정한 판례는 거의 없음(대부분 성과부진 문제를 근로자의 비위행위, 무단결근 등 징계사유와 함께 해고사유로 인정)
	○ 해고 사유와 유형(78~84쪽) - 통상해고의 사유로 ⅰ) 근로자 부상질병, 건강상태로 인한 해고 ⅱ) 유죄판결에 의한 해고, ⅲ) 능력부족, 업무성적 불량으로 인한 해고, ⅳ) 직제규정, 합병 등 직제폐지에 따른 전보, 전적 불응에 따른 해고, ⅴ) 파산선고를 받은 사업주, 청산과정에서의 해고 등(74쪽) - 업무능력 부족 및 근무성적 부진 자체도 근로자의 일신상 사유로 근로제공이 불가능한 경우와 동일 취급하여 통상해고 사유로 규정	► 노동관계의 특별법인 근로기준법에 규정한 바 없는 통상해고를 자의적으로 개념화, 해고 사유를 확대 해석하고 있음. - 정부지침이 열거한 사유는 근로자의 일신상 사유로 근로제공이 불가능한 경우이지 단순히 해당 사실만으로 근로기준법 제23조의 정당한 해고 사유로 볼 수 없음. - 근로자의 일신상 사유로 근로제공이 불가능한 경우와 근무성적 부진을 동일선상에 놓고 해고 사유가 된다는 식의 논리구성은 타당하지 않으며, 근기법상 해고제한규정을 회피하기 위한 논리로 오용케 될 우려가 큼.
	○ 해고시 절차의 준수 : 단체협약 또는 취업규칙 등에서 징계사유의 사전통지, 징계위원회 개최 등을 규정하고 있는 경우, 근로자 보호의 취지에	► (대법원 2006. 11. 23. 선고 2006다49901판결)에 대해서 "적법절차와 자연적 정의의 요청에 의하면, 해고는 정당한 권한을 가진 자에 의하여 행해져야

구분	정부 지침의 주요 내용	문제점
Part Ⅱ. 근로계약 해지 및 해고절차	서 관련 규정을 해고의 효력 요건으로 보는 것이 일반적임(94쪽) - 다만, 해고의 절차 등에 관한 사항을 별도로 규정하고 있지 않은 경우에는 절차를 거치지 않았다고 하더라도 무효로 보지는 않음(각주: 대법원 2006. 11. 23. 선고 2006다49901판결)	하며, 피 해고자에게 서면 통지와 변명 기회를 부여하여야 할 뿐만 아니라 해고를 결정하는 기관은 공정하게 구성되어야 하므로, 최소한 징계사유에 대한 사전 통지와 변명기회의 부여는 단체협약 등에 그 규정이 없는 경우에도 인정되어야 하며, 이러한 해석이 법 23조 1항의 정당한 이유라는 규정을 두어 절차적 정당성을 요구하는 것"이라는 비판이 제기되는 사례를 굳이 인용한 것은 매우 부적절함(근로기준법주해Ⅱ, 노동법실무연구회, 120~121쪽).
	○ 업무능력의 현저한 결여, 근무성적 부진 등은 별도의 징계사유가 없더라도 통상해고 사유(109~112쪽) - 업무수행 능력의 결여는 근로제공 의무의 불완전 이행으로 근로계약 해지 사유에 해당	► 우리나라의 경우 저성과자 해고가 징계해고를 중심으로 법리 형성되어 있음에도 정부지침은 업무능력의 결여, 근무성적 부진 자체로도 폭넓은 해고가 인정되는 것처럼 호도하고 있음. - 판례는 업무능력 결여, 성과부진이 사회통념상 고용관계를 유지할 수 없을 정도로 현저하게 근로자의 책임 있는 사유에서 기인하는 경우 징계처분 대상으로 해고의 정당성을 인정해 옴. - 성실한 근로제공에도 불구하고 단순히 근무성적의 부진만을 이유로 해고할 경우 해고의 정당성이 인정될 수 없음.
Part Ⅱ. 근로계약 해지 및 해고절차	○ 해고 사유의 근거 명확화(113~116쪽) - 취업규칙, 단체협약 등에 업무능력결여, 근무성직 부진에 따른 해고사유를 근거규정 마련하라 - "근무성적이 현저히 불량한 경우"는 징계해고가 아닌 통상해고 사유의 하나로 규정하는 것이 바람직함(114쪽). - 기존 해고사유 등에 관한 규정을 구체화하는 방식으로 취업규칙 변경시 불이익 변경으로 볼 수 없음(115~117쪽). - 행정법원 2011. 8. 25. 선고 2010구합42263 등 역량향상프로그램 일방도입을 취업규칙 불이익변경으로 보지 않은 특정 하급심 판례 인용	► 해고시 징계위원회 및 인사위원회 등의 절차를 배제하는 수단 안내 - 앞서 해고 절차 부분(96쪽)에서 "통상해고와 징계해고 사유가 서로 구분되어 규정된 경우에는 통상해고를 할 때에 취업규칙 또는 단체협약에 정한 징계절차를 반드시 거칠 필요 없음"이라고 안내하고, 성과평가에 따른 해고는 통상해고 사유로 규정하라고 하여 사실상 징계절차를 배제하는 방법을 안내하려는 의도임. ► 기존 해고사유 등을 구체화 하는 방식으로 취업규칙을 변경하면 불이익 변경시 동의절차를 회피할 수 있다는 식으로 안내하고 있음. ► 인용한 행정법원 2010구합42263, 서울고법 2013나25400 판례는 역량향상 프로그램의 도입에 대해 근무성적 불량해고를 규정한 취업규칙을 세분화

구분	정부 지침의 주요 내용	문제점
		한 것으로 보아, 불이익변경이 아니라는 취지이나 동 사건은 대법원 판례도 아니고, 축적된 판례 경향도 아님, 특정판례를 인용하여 일반화 시키는 것은 무리임(노조와의 동의, 협의절차를 무시하는 논리로 오용될 우려)
	○ 객관적, 공정한 평가 / 노사협의회·노조참여 / 상대평가보다 절대평가 합리성 인정 / 평가결과 공개 및 이의신청 절차마련(118~137쪽) - 근로자의 업무능력, 근무 등에 대한 평가는 사용자의 고유의 인사경영권이므로 원칙적으로 그 내용, 방식 등에 재량권 인정 - 사용자 주관적인 정성적인 요소가 포함되더라도 자의적이라거나 권한 남용으로 단정할 수 없음.	► 저성과자에 대한 통상해고 지침의 최대 문제인 근로자 인사평가의 공정성 및 객관성을 담보할 수 없다는 문제점을 보완하기 위한 방안을 강조하기는커녕 오히려 사측의 평가 재량권만 강조 - 사용자의 재량권 남용으로 해고 남용 등이 속출하고 있는 현실을 감안하지 않은 채 사측의 자의적 정성평가 및 인사평가 재량권 남용여지를 안내하는 식으로 내용 구성
	○ 교육훈련 기회 제공 / 배치전환 등 해고 회피노력 선행(138~144쪽) - 평가를 통한 역량프로그램 대상자 선정 - 실제 업무능력 향상을 위한 방향(충분한 시간 부여 등)으로 설계 - 대인관계가 원만하지 않는 근로자, 상급자와의 인간관계가 원만하지 못하여 업무성과가 부진한 경우도 배치전환 필요성 고려 ○ 해고 대상자 선정(137~141쪽) - 교육훈련, 배치전환 등 개선기회 제공해도 개선이 없는 경우 등	► 저성과자 교육프로그램 운영하는 대기업의 46%가 7일이내의 역량강화 교육기간 실시하는 등 형식적 저성과자 퇴출프로그램이 운영되는 현실에서 정부의 지침은 기업에 저성과자 해고제도 확산의 빌미만 제공(경향신문,「대기업, 저성과자 교육 고작 일주일」, 2016. 1/6) ► 사측의 퇴출 종용을 위한 왕따 관리 프로그램의 빌미 제공 - 대인관계 및 상급자와 인간관계의 원만치 못함을 사측의 인사상 문제점은 외면한 채 근로자의 책임으로 전가
기타 Part Ⅰ. 관련 채용에서 퇴직까지 (11~72쪽)	○ 채용에서 평가, 보상, 교육·배치전환, 퇴직관리까지 성과주의 임금체계 및 인사관리 강조 ○ 사업주가 임금 지급방식이나 임금체계 자체를 바꾸는 것은 인사관리나 경영상 필요에 의한 것으로 취업규칙 불이익변경에 해당하지 않음(대구고법 2005나4889). 다만, 전체적으로 임금을 낮출 목적으로 임금체계 변경이 이루어진다면 근로자에게 불이익으로 판단	► 객관적이고 공정한 평가의 한계를 무시한 채, 연·공급 임금체계를 근거없이 악으로 규정하고, 성과주의 임금체계 및 성과주의 인사관리 강조 ► 성과연봉제 등 임금체계 변경이 원칙적으로 노조나 근로자대표의 동의대상이 아닌 것을 전제로 논리 전개 - 임금체계변경의 목적과 관계없이 그 결과로 불이익 초래시 불이익변경임 - 하급심 판례(2005나4889) 하나를 일반화시키는 지침을 내는 것 자체가 비

구분	정부 지침의 주요 내용	문제점
	○ 휴대폰, 문자, 이 메일 등 전자적 방법에 의한 서면 해고 통지 - 예외적으로 전자결제 체계 완비하여 전자문서 모든 업무과정 관리하거나 원거리에 있는 등 특별한 사정이 있으면 e-메일 등에 의한 통지 인정	이성적임(근로자 보호취지에 입각한 해석을 해야 할 노동부가 가장 핵심적 근로조건 변경문제에 대해 경영권 이론 입장에 서는 것은 모순) ► 사측의 일방적 문자 및 이 메일 등 편법적 해고 통지의 빌미 제공
	○ 퇴직에 대한 사전적 경고와 준비, 근로자의 선택과 이에 대한 지원이 선순환을 이루도록 프로세스를 혁신하고 시스템을 구축하여야 함 - 사전적 퇴직 경고(또는 구조조정 사전예고제)를 통해 고용의 예측 가능성을 높이는 것이 중요함	► 반강제적 구조조정의 수단인 희망퇴직 대상통보 등을 인력운영의 선순환 프로세스로 자의적 해석하여 장려하는 격 - 최근 정부의 저성과자 해고 지침 시행을 앞두고 희망퇴직 등이 속출하고 있는 것이 선순환이고, 바람직한 것인가?
	○ 기간제법 시행 이후 갱신기대권 부정(68-69쪽) - 기간제 근로계약 …… 기간제법 시행 이후에 신규로 근로계약을 체결되었다면 2년을 초과하는 갱신기대권이 인정될 수 없다고 봄(서울고등법원 2011. 11. 23. 선고 2011누398, 대법원 2014. 12. 31. 선고 2012두1402)	► 기간제법 이후에도 갱신기대권 인정한 판례 고의적 배제 - 이른바 '기간제법 시행 이후에도 갱신기대권 인정'하는 판례(서울고등법원 2014. 11. 16. 2013누53679)도 존재하고, 기간제법의 취지(기간제 근로자의 고용안정 보장)에 비추어 볼 때 이를 긍정하는 것이 타당함

<첨부 2>

취업규칙 운영과 해석지침 개정안의 주요내용 및 문제점

구분	정부 지침의 내용	문제점
지침 개정 배경 등	○ 정년 60세 법제화에 따른 임금체계 개편(전문 등) - 정년을 60세로 법제화 하면서 … 노사 모두에게 연공급 중심의 임금체계를 개편해야 할 노사 공동의 책무부여 - 임금체계 개편에 따른 취업규칙 변경이 사회통념상 합리성이 있으면 근로자 동의없는 변경에 효력 인정	► 고령자고용촉진법은 정년 60세 법제화 하면서 연·공급 임금체계 개편 강제하고 있지 않음. - 절대다수 노동법 학자가 60세 정년의무화에 따른 임금체계 개편조항을 권고 규정으로 해석(정부지원을 위한 근거규정), 더욱이 법률은 특정 연공급 체계의 개편을 요구하고 있지 않음.
	○ 취업규칙 불이익변경 동의받지 못하면 사회통념상 합리성 법리 적용 가능성 검토(60쪽) - 이와 관련 판례는 불이익변경에 동의를 받지 못한 경우에도 일관되게 사회통념상 법리를 적용하여 그 효력 여부와 형사처벌 여부를 판단하므로 …판례를 토대로 한 기준 마련	► 노조 및 근로자 과반수 동의를 받지 못하면 강행규정인 근로기준법 제94조에 따라 불이익변경의 효력 자체가 무효임. - 판례는 근로자 동의 없는 취업규칙 변경의 효력에 일관되게 부정하고 있지 일관되게 사회통념상 합리성 법리를 적용한 바 없음. - 극히 예외적이고 드물게 '사회통념상 합리성'이 인정된 판례를 분석하여 일반적 기준인 냥 지침으로 제시하는 것은 사측의 일방적인 임금체계 개편을 지원하기 위한 의도로 밖에 볼 수 없음.
취업규칙 작성·변경 절차	○ 상시 4명 이하 사업장의 사업주가 임의로 취업규칙을 작성하는 경우 법에 따른 취업규칙을 효력을 인정받기 어려워 취업규칙 변경절차, 취업규칙에 위반한 근로계약의 무효 등 규정은 적용되지 않음(8쪽) - 행정해석(2005. 12. 28. 근로기준팀 -2046)	► 대법원은 4인 이하의 사업장의 사용자가 일단 취업규칙을 작성한 경우 근로계약의 내용으로 편입된다는 입장(대법원 2008.3.14. 선고 2007다1418 판결)인 바, 사업주의 취업규칙의 변경은 근로계약의 내용을 변경하는 것이어서 반드시 개별 근로자의 동의가 필요하다고 서술해야 타당함.
	○ 취업규칙으로서 효력이 발생한 이후에는 법 제14조에 따라 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 두어야 그 효력이 지속되는 것은 아님(10쪽)	► 이와 같은 지침의 불필요한 언급은 자칫 취업규칙을 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 할 사용자 의무(근로기준법 제14조 제1항)가 필요가 없다는 잘못된 인식을 줄 우려 큼.

구분	정부 지침의 내용	문제점
취업규칙 작성・변경 절차	○ 취업규칙의 변경은 기존의 근로조건 또는 복무규율에 관한 사항을 개정하는 것으로 취업규칙에서 정하고 있지 아니한 근로조건 또는 복무규율에 관한 사항을 새롭게 정하는 작성(제정)과 구별됨(13쪽).	► 대법원은 종전의 취업규칙에서 정하고 있지 않았던 불리한 규정을 새로 신설하는 경우도 취업규칙의 (불이익)변경으로 봄(대법원 1997. 5. 16. 선고 96다2507 판결)
	○ 종래의 규정이 불명확하거나 포괄적이어서 그 내용을 세분화하여 구체화하는 차원에서 취업규칙 내용을 변경하는 경우에는 … 불이익한 변경으로 보지 않는 것이 판례의 입장임(18쪽) - 특히 서울행정법원 2010구합42263 판결 인용	► 정부가 나서서 사실상 취업규칙 불이익 변경하면서도 근로자 집단적 동의절차 거치지 않아도 되는 꼼수를 직접 강조해가며 안내하고 있음 - 특히 지침이 인용한 역량향상프로그램의 도입에 대해서 근무성적 불량해고를 규정한 취업규칙을 세분화한 것으로 보아, 불이익변경이 아니라는 취지의 동 판례(행정법원 2010구합42263)은 대법원 판결도 아니고, 축적된 판례의 경향도 아님, 특정판례를 인용하여 일반화 시키는 것은 무리임(역량향상프로그램 도입시 노조와의 동의절차를 무시하는 논리로 악용될 우려)
	○ 사용자 측의 개입이나 간섭이 배제된 상태에서 사업 또는 사업장의 기구별 또는 부서별 단위로 모이거나 SNS, 온라인 게시판 등을 통해 근로자 상호간에 충분히 의견을 교환하여 찬반의견을 … 취합하는 방식도 허용(28쪽)	► 정부지침이 편법적인 근로자 집단동의 절차 안내하는 격 - 법원 판례 등에서 SNS, 온라인 게시판 등을 통해 근로자 상호간에 의견교환 및 찬반의견 취합하는 방식을 인정한 바 없음(노동부 자의적 해석)
	○ 근로자 상호간에 의견교환 과정이 있거나 충분한 시간이 있었다면 “회람하는 문서에 서명하는 방식”도 회의방식에 의한 동의로 볼 수 있음 - 대법원 2001다18322 판결 인용(28쪽 하단~29쪽)	► 근로자 상호간에 의견교환 과정이 있거나 충분한 시간이 있었다면 “회람하는 문서에 서명하는 방식”도 회의방식에 의한 동의로 볼 수 있다는 대법원 판례는 IMF의 특수한 사정 하의 판례로서, 학계의 비판이 큰 판례로, 이를 잘못 악용할 경우 ‘사실상 강요된 서명동의서 회람’를 ‘적법한 집단적 회의방식에 의한 동의’로 둔갑시킬 위험이 매우 큼 - 현행법 제94조의 입법근거가 된 대법원 판결(77다355 등)에 입각하여 근로자 과반수의 동의는 회의방식에 의한 집단적 동의임을 설명해야지 특수한 예외를 부각시켜 악용소지를 키워서는 아니 됨.

구분	정부 지침의 내용	문제점
취업규칙 작성・변경 절차	○ 사용자는 불이익하게 변경된 취업규칙을 기득권이 침해되지 않는 근로자에 대해서는 별도의 동의절차 없이 적용할 수 있음(34쪽) - 신규 입사자의 경우 불이익 변경 이후 변경된 취업규칙에 따른 근로조건을 수용하여 입사한 것으로 당연히 불이익하게 변경된 취업규칙의 효력이 인정될 수 있음	► 과거 신규입사자, 대졸 초임 삭감 등에 악용되었던 취업규칙 변경사례를 들어 노조 및 근로자 과반동의 절차 배제방법 안내하는 격 - 신규 입사자에게 동의절차 없이 취업규칙을 적용할 수 있다는 이유로 이를 소개하는 것은 부적절함.
	○ 기업이 경영상 필요성 등 여러 가지 사정상 취업규칙의 변경이 반드시 필요하고 그 내용도 합리적인 것으로 인정되는데도(35쪽) - 근로자집단의 동의를 받지 못하여 사용자의 경영권이 과도하게 제한을 받게 되고 경영환경 변화에 대응하지 못하는 경우 기업은 경쟁력을 상실하고 근로자는 고용이 불안정해지는 등의 문제가 발생할 수 있음	► 기업이 빈번히 동의절차를 무시한 채 취업규칙 변경하는 것을 방지해야 하는 정부의 책무를 간과한 채, 일방 변경의 빌미 제공 - 취업규칙의 집단적 동의를 배제하는 '사회통념상 합리성 이론'을 원용하기 위한 고용노동부의 자의적 입장과 근거 제시에 불과함.
	○ 근로조건의 저하가 근로자가 받아들이기 어려울 정도로 과도하게 불이익하지 않으면 다른 판단요소 등을 종합적으로 고려하여 사회통념상 합리성을 인정할 수 있음(37쪽)	► 이와 같은 내용은 "사회통념상 합리성 법리는 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받도록 한 근로기준법을 사실상 배제하는 것이므로 제한적으로 엄격하게 해석해야 한다(대법원 2010. 1. 28. 선고 2009다32362)" 라는 대법원 판례의 입장을 반하는 확대해석임.
	○ 합병 등 기업조직의 변동 시 근로조건의 통일을 위하여 퇴직금 지급률을 낮추어 조정하는 등의 경우 변경의 필요성을 인정할 수 있음 - 대법원 99다 70846 판결 인용(37쪽)	► 인용한 판례는 정년이 10년이나 연장되는 등 다른 근로조건의 개선 사항을 고려해서 사회통념상 합리성이 인정된다는 판례이지, 합병 등의 경우 근로조건의 통일을 위하여 무조건 합리성이 인정된다는 판례가 아님 - 판례를 부분적으로만 인용하여 완전히 왜곡 해석한 사례임
	○ 변경된 근로조건이 동종업계와 비교할 때 유독 불리하다고 평가할 수 없는 상황에서 경영상의 어려움 등으로 인하여 불가피하게 이를 변경하고자 하는 경우 사회통념상 합리성을 인정할 있음(41쪽)	► 대법원 판례가 제시한 여러 판단표지를 종합해서 사회통념상 합리성이 인정될 수 있는 것이지 단지 경영상의 어려움이 있다는 것만으로 근로기준법 제94조를 배제할 수 없음. "사회통념상 합리성 법리는 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받도록 한 근로기준

구분	정부 지침의 내용	문제점
		법을 사실상 배제하는 것이므로 제한적으로 엄격하게 해석해야 한다는 (대법원 2010. 1. 28. 선고 2009다32362 판결)"는 취지에 반함.
사회통념상 합의성 판단	○ 사회통념상 합리성 적용여부(36쪽) - 기업이 정년 60세에 따라 … 합리적 수준의 임금피크제 도입 등 방안을 마련하고 사용자가 동의를 얻기 위하여 성실히 노력했음에도 근로자 측의 교섭거부 등으로 동의를 얻지 못하고 취업규칙을 변경한 것이라면 … 사회통념상 합리성 법의 적용가능성 검토	► 합리적 수준의 임금피크제 도입이 어느 정도 수준인지, 사용자의 동의를 얻기 위한 성실한 노력수준이 무엇인지에 대한 설명이 없어 근로자 측이 임금피크제 도입 요구에 불응하면 사회통념상 합리성 법리 적용이 가능한 것처럼 서술하고 있음.
	○ 사회통념상 합리성 판단(36~41쪽) - 사회통념상 합리성 판단는 아래의 6가지 요소를 종합적으로 판단 ① (근로자의 불이익 정도) 고령자고용촉진법 입법취지를 형해화 할 정도의 낮은 임금 감액이 아니라면 불이익이 크다고 보기 어려움 ② (사용자측의 변경 필요성) 정년 60세 하에서 고령자고용촉진법이 노사 모두에게 임금피크제를 포함한 임금체계 개편 의무를 부여하고 있는 점을 고려할 때 취업규칙 변경 필요성이 있음 ③ (변경된 취업규칙 내용의 상당성) 근로자 측이 입게 되는 불이익 외에 경과조치 유무, 동종 기업, 사회 일반적으로 기대되는 합리적인 임금 수준, 단계적 감액 등을 고려하여 변경 내용의 상당성 여부 판단 ④ (다른 근로조건의 개선 여부) 근로시간 단축, 업무의 조정, 복리후생 제도의 유지·확대 등을 고려 ⑤ (노동조합 등과의 충분한 협의 노력 등) 사용자가 취업규칙 변경의 권한이 있다는 이유만으로 「고령자고용촉진법」의 입법 취지를 무시한 채 일방적으로 변경하거나 형식적으로만 협의를 거친 경우에는 그 합리성이 인정되기 어려움. 교섭거부시 사회통념상 합리성 인정	► 앞서 지침은 "법정 정년연장과 이에 따른 임금피크제 등이 … 임금감액, 조정을 수반하는 경우 불이익한 변경이라고 판단함이 타당함" 라고 서술하면서도 정부지침은 판례에서 극히 예외적으로만 인정해온 사회통념상 합리성 법리에 따라 60세 정년 시행과 임금피크제 도입이 노조 및 근로자 과반수의 동의절차 없이 가능하다는 식의 자의적 해석을 하고 있음. ► 지침은 판례가 제시한 6가지 판단지표중 하나만 충족하면 곧 합리성이 인정되는 것처럼 서술되어 있는 것도 문제임. - (취업규칙 변경으로 근로자가 입게 되는 불이익 정도)관련 정부지침은 합리적 기준선도 없이 "고령자고용촉진법 입법취지를 형해화 할 정도의 낮은 임금감액 및 근로조건 변경이 아니라면 불이익이 크다고 보기 어려움"라고 서술하고, 61쪽에 인용된 판례(서울지법 2008. 8. 1. 2007가합111716)도 상식을 벗어난 임금감액 사건을 예시로 들어 자칫 법정 정년보장을 이유로 과도한 임금감액만 아니면 큰 폭의 임금감액이 허용되는 것으로 오해할 소지도 다분함. - (노동조합 등과의 충분한 협의 노력 등)과 관련하여 노조나 근로자 측이 임금피크제 도입 교섭요구에 불응하면 무조건 사회통념상 합리성이 인정되는 것으로 오해할 수 있음.

구분	정부 지침의 내용	문제점
	⑥ (동종 사항에 관한 국내 일반적인 상황 등) 임금피크제 도입에 따른 취업규칙 변경 내용과 관련 하여 지역 내 동종 업계 등의 임금감액 비율, 대상 조치, 교섭 및 합의 경향 등을 고려할 수 있음 ○ 직무급, 성과급 관련 사회통념상 합리성 판단(65쪽) - 성과중심의 임금체계 도입은 사용자의 경영판단 사항으로 근로조건 불이익 변경으로 볼 수 없음. - 대구고법 2005나4889 판결 인용(연봉제 도입이 불이익변경 아님) ○ 성과중심의 임금체계로 근로자 일부에게 불이익한 결과로 인하여 근로조건의 불이익변경에 해당하는 경우에도, 사회통념상 합리성 판단요소를 고려하여 판단할 필요(66쪽) - 근로자에게 차별없이 공정한 기회보장, 공정한 평가제도를 통해서 일정한 성과를 내면 임금이 높아질 수 있다는 기회가 보장되면 사회통념상 합리성 인정(부산지법 2014. 5. 20. 선고 2013가단21019 판결)	► 매우 자의적인 정부의 입장에 불과함. 임금체계 변경으로 일부 근로자라도 임금감액이 생기면 불이익변경에 해당되는 것 - 성과중심의 임금체계 도입이 경영권 사항인지 여부와 관계없이 임금, 근로조건 불이익 변경을 초래하면 노조 및 근로자 과반수의 동의 필요 - 하급심(대구고법) 판례 하나를 가지고 일반화시키는 지침을 내는 것 자체가 비이성적임(근로자 보호취지에 입각한 해석을 해야 할 노동부가 가장 핵심적 근로조건 변경문제에 대해 경영권 이론 입장에 서는 것 자체가 모순) - 지침에서 교원업적 평가에 관한 특정 하급심 판례(부산지법 2014. 5. 20. 선고 2013가단21019)를 일반화하여 차별없이 공정한 기회가 보장되면 근로조건의 불이익변경이 초래되더라도 사회통념상 합리성이 인정될 수 있다는 식의 설명은 자의적 확대해석에 해당됨.
	○ 취업규칙과 근로감독관의 업무(67쪽 이하)	► 과연 근로감독관이 취업규칙 변경의 사회통념상의 합리성을 제대로 판단할 수 있을지 의문임(2015. 12. 30. 노동부 주최, 전문가 간담회, 이정 교수 비판 참조). 현행 근로기준법을 엄정 집행·감독해야 할 근로감독관이 임의로 사회통념상 합리성을 운운하며 사측의 불법행위(동의없는 취업규칙 불이익변경)를 용인하는 것이야 말로 명백히 위법한 행정방임에 해당됨. 이러한 문제를 야기할 수 있는 근로감독관 지도지침을 만드는 의도가 무엇인가?